

1503778-89.2020.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... "lojinha da 39" devido ao fato de o narcotráfico ser bem intenso naquele ponto da cidade (cf. gravação audiovisual de fls. 142/145).

Oliveira ainda acresceu que o réu já era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido preso noutras ocasiões pela mesma prática ilícita nas proximidades daquele local.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1503778-89.2020.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503778-89.2020.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN SOUZA OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

JUAN SOUZA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 8 de dezembro de 2020, por volta das 08:30 horas, na Avenida Professor Doutor Alfredo Amaral Gurgel, nº 812, Jardim Roberto Selmi Dei, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 7 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido total de 11,06 gramas, e 2

microtubos do tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido total de 0,85 grama, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado o acusado (fl. 109) e apresentada defesa preliminar (fls. 113/114), a denúncia foi recebida (fls. 115/116). O réu foi citado (fl. 137).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 142/145).

Em debates orais, a DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Ilustre Defensor Público postulou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso contrário, o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da mesma lei e a aplicação do privilégio, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 142/145).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e dos laudos de constatação provisória (fls. 13/15 e 16/18) e definitiva de entorpecentes (fls. 73/74 e 75/77), com resultados positivos para cocaína e THC (maconha).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado declarou ser usuário de cocaína e maconha e negou a prática do tráfico de entorpecentes. Afirmou que estava no local dos fatos sentado sozinho, pois acabara de comprar 3 porções de maconha e iria fazer uso delas. Não tinha consigo cocaína e aduziu que as demais porções de droga foram encontradas pelos policiais nas proximidades do local da abordagem, mas não lhe pertenciam. Já o numerário apreendido em seu poder era proveniente do auxílio emergencial (fl. 05).

Em juízo, tornou a negar a imputação, mas modificou sua versão e passou a afirmar que, na data dos fatos, pela manhã, estava sozinho parado em uma esquina quando foi abordado por policiais militares. Tinha "virado" a noite e trazia consigo 2 pinos de cocaína e algumas porções de maconha, além de certa quantia em dinheiro oriunda do auxílio emergencial. Não tinha objetos para fazer uso de entorpecentes e na ocasião pretendia consumir primeiro os pinos de cocaína e depois as porções de maconha. Negou ter admitido aos policiais a destinação das drogas para a venda, pois eram para o seu próprio consumo. Negou qualquer envolvimento com o narcotráfico e declarou ser apenas usuário de tais substâncias. Confirmou que o local onde foi abordado é conhecido como ponto de venda de drogas. Na época do ocorrido estava desempregado (cf. gravação audiovisual de fls. 142/145).

Ocorre que, apesar das versões exculpatórias exaradas pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Boleta e Oliveira relataram que, na data mencionada, no período da manhã, durante patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela intensa prática do narcotráfico, visualizaram o acusado sozinho,

agachado em uma esquina, o que lhes despertou suspeita. Efetuaram a sua abordagem e, em busca pessoal, localizaram no bolso de sua blusa 7 porções de maconha embaladas individualmente e 2 eppendorfs de cocaína, além da quantia em dinheiro de R\$ 67,50 em notas trocadas. No momento da abordagem apenas o imputado estava naquele local. Indagado, ele de imediato admitiu a comercialização dos entorpecentes e disse que o dinheiro era oriundo do auxílio emergencial. Esclareceram que o local é conhecido como “lojinha da 39” devido ao fato de o narcotráfico ser bem intenso naquele ponto da cidade (cf. gravação audiovisual de fls. 142/145).

Oliveira ainda acresceu que o réu já era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido preso noutras ocasiões pela mesma prática ilícita nas proximidades daquele local.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Na hipótese em exame, a conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida sobretudo pela natureza, diversidade e forma de acondicionamento dos tóxicos apreendidos (2 microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido total de 0,85 grama, e 7 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido total de 11,06 gramas, já embalados e prontos para a revenda e entrega a terceiros – cf. auto de fls. 08/09, fotografia de fl. 12 e laudos de fls. 13/15, 16/18, 73/74 e 75/77).

Também houve a apreensão em poder do acusado, no mesmo contexto fático, de quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 67,50), certamente relacionada à prática ilícita em questão (cf. auto de fls. 08/09 e guia de fl. 72).

Note-se, a propósito, que o imputado não apresentou nenhuma prova cabal da suposta origem lícita do referido numerário, mas apenas a alegação vaga e genérica de que era proveniente do auxílio emergencial, o que reforça a conclusão de que era mesmo oriundo da nefasta mercancia, até porque foi bem demonstrado nos autos que na época dos fatos o agente estava desempregado e sem qualquer ocupação lícita.

Frise-se ainda que, ao ser abordado, o acusado de imediato admitiu aos castrenses atuantes na ocorrência a dedicação ao comércio espúrio no local dos fatos.

Inviável cogitar-se, ademais, da atribuição da propriedade das drogas a terceiros, eis que, como salientado pelos policiais, não havia nenhuma outra pessoa por perto do réu no momento da abordagem.

Além disso, já havia informações no meio policial dando conta da frequente prática do tráfico de drogas no local dos fatos e nas suas imediações, consoante se infere do teor dos depoimentos dos milicianos ouvidos em solo judicial e dos documentos de fls. 80/82, que apontam a existência de denúncias anônimas alusivas a tal prática ilícita naquelas áreas.

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, afastam a veracidade das frágeis versões exculpatórias exaradas pelo réu e confirmam a ocorrência, na espécie, da guarda e do transporte das drogas para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de drogas, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito as substâncias entorpecentes, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, a pretensão defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que os entorpecentes apreendidos eram pertencentes ao réu e se destinavam, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros – ainda que de forma gratuita -, não sendo unicamente para o uso próprio do imputado.

Vale ressaltar, nesse ponto, que não foi apreendido com o réu nenhum objeto ou petrecho comumente usado para o consumo das drogas que possuía (cocaína e maconha), circunstância que fragiliza ainda mais as versões inverossímeis por ele apresentadas.

É consabido, ademais, que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples guarda temporária da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

No entanto, é de se afastar, no caso em exame, a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06 – cometimento da infração nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares e outros locais assemelhados -, uma vez que o local mencionado na denúncia (Unidade de Saúde da Família Nefália de Oliveira Lauer) se situa a 330 metros de distância do local dos fatos (cf. laudo pericial de fls. 92/95).

Cabe assentar, nesse aspecto, que a expressão “imediações” encerra conceito jurídico relativamente indeterminado, cujo preenchimento o Juiz deve efetuar tendo em vista as circunstâncias do caso concreto e sempre à luz da finalidade do dispositivo, que é proteger tais locais contra as investidas do tráfico. Assim, não há uma medida aritmética. Incide a majorante se o agente pode alcançar, com facilidade e em pouco tempo, os locais especialmente protegidos, o que não ocorre no presente caso, dada a grande distância aferida (equivalente a mais de 3 quarteirões).

Confira-se a lição de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

“O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida aritmética rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem” (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006, Ed. Saraiva, 2007, p. 135).

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

Por fim, na derradeira etapa do procedimento trifásico, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, e não havendo prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, e considerando ainda a pequena quantidade de drogas apreendidas (0,85 grama de cocaína e 11,06 gramas de maconha),

as penas devem ser reduzidas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilégio), no grau máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo assim o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo.

Convém destacar, diversamente do sustentado pelo d. órgão acusatório em alegações finais, que a existência de ações penais em andamento pela mesma espécie delitiva (Procs. nº 1501672-91.2019.8.26.0037 e nº 1503322-42.2020.8.26.0037, ambos em curso na d. 1ª Vara Criminal local – cf. certidão de fls. 54/55) não pode ser tida como fator indicativo de que o agente vem se dedicando de forma intensa e habitual a atividades criminosas relacionadas ao narcotráfico.

Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos policiais e processos criminais em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Apoiada nesse entendimento, a Corte Suprema vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso (ainda que em fase recursal) para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II – A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Recurso Extraordinário nº 1.283.996 – AgR – 2ª Turma – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – j. 11.11.2020).

De igual modo, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento da Suprema Corte já foi adotado tanto pela E. 6ª Turma (AgRg no AgRg no HC nº 654.773/MT, Rel. Min. Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; AgRg no HC nº 673.030/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021) quanto pela E. 5ª Turma (Habeas Corpus nº 664.284/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.09.2021), tendo a E. 3ª Seção, recentemente, em decisão unânime, no julgamento do EAREsp nº 1.852.098/AM (DJe 03.11.2021, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik), chancelado o entendimento no sentido de considerar “[...] inidôneo o afastamento da referida causa de diminuição de pena com base apenas em ações penais em andamento, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade”.

Frise-se, ainda, que a referida Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a mencionada orientação, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e 1.977.180/PR (Tema 1.139), fixando a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Insta consignar, por oportuno, que o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentara o entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é

equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90.

Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que possuía entendimento sumulado em sentido diametralmente oposto ao acima descrito, cancelou o Enunciado 512 de sua Súmula, alinhando-se à jurisprudência do Pretório Excelso.

E, por fim, recentemente a legislação em vigor veio a contemplar referido posicionamento, consoante se infere do teor do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, acrescido pela Lei nº 13.964/19, que dispõe, in verbis:

“Art. 112 (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Desse modo, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu será cumprida inicialmente em regime prisional aberto, tendo em vista o quantum da reprimenda e a ausência de circunstâncias capazes de justificar a imposição de regime mais gravoso.

Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso em exame, faz jus o imputado à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal, já que preenche os pertinentes requisitos legais para a substituição.

Assim, converto a pena corporal acima aplicada em penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (arts. 43, inciso IV, e 46, ambos do CP), pelo mesmo prazo da pena reclusiva (art. 55 do CP), e de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social desta comarca (arts. 43, inciso I, e 45, § 1º, ambos do mesmo codex), a serem especificadas na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu JUAN SOUZA OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da primeira por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e por prestação pecuniária, na forma retroespecificada, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Em caso de descumprimento do benefício da substituição, o regime prisional inicial de cumprimento da pena carcerária será o aberto.

Tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do numerário apreendido (cf. auto de fls. 08/09 e guia de fl. 72), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA